

“APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ...

1503747-30.2019.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

JONATHAN GIMENEZ e SÁVIO CONCEIÇÃO DA COSTA, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 17h00, na Droga Raia, localizada na Avenida Ademir de Barros, nº 2158, Loteamento Silex, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios entre si, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo, 5 (cinco) pilhas e a quantia de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais) em espécie, bens pertencentes à vítima Droga Raia.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, os acusados chegaram no estabelecimento vítima conduzindo uma motocicleta de Honda/Biz. Ato contínuo, SÁVIO desceu de tal veículo, entrou na farmácia e, mediante grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo que portava, anunciou o assalto e subtraiu 05 (cinco) pilhas e quantia em dinheiro do caixa. Na sequência, JONATHAN também desceu da motocicleta e se deslocou até a sala onde fica o cofre do estabelecimento vítima, de onde subtraiu outra soma em dinheiro. Após, os acusados se evadiram do local na posse da totalidade dos bens subtraídos, quais sejam, 5 (cinco) pilhas e a quantia de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais) em espécie.

Diz também a denúncia que, em sede de investigação policial, Thais Santiago Santos Souza, representante da vítima, reconheceu fotograficamente SÁVIO e JONATHAN como os autores do roubo (fl. 06). Posteriormente, Thais também realizou o reconhecimento pessoal de SÁVIO (fl. 21).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 254). Os réus foram citados (fls. 274 e 276) e apresentaram resposta à acusação (fls. 282/283). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 288/289), seguindo-se oitiva da representante da vítima, testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 317/321).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 324/327 e 348), enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial e ausência de reconhecimento pessoal do corréu SÁVIO. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, em relação ao acusado Jonathan, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e imposição de regime inicial diverso do fechado (fls. 354/365).

É o relatório.

DECIDO.

Anoto, por primeiro, inócua nulidade do reconhecimento realizado na fase extrajudicial.

A inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Destaco que a providência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal somente deve ocorrer quando possível e que sua inobservância longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento

determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020).

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova - Violação ao art. 226 do CPP - Mera recomendação - Desclassificação para furto - Descabimento - Grave ameaça devidamente configurada - Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio - Não ocorrência - Indivíduo previamente ajustado ao comparsa - Teoria monista da ação - Pena e regime bem fixados - Recursos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 0002657-36.2017.8.26.0642; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELAS PARTES AO FINAL DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstado o inquérito policial se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a referida prova ainda será contrastada com os demais elementos de convicção reunidos no procedimento investigatório, e analisada tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado singular, bem como contestada pela defesa, o que impede a sua invalidação nesta oportunidade" (RHC 66.352/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

Rejeito, destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento extrajudicial sustentado pela d. Defesa.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito a ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu JONATHAN GIMENEZ.

Thais Santiago Santos Souza, representante da vítima, declarou que no dia dos fatos dois roubadores entraram na farmácia, um deles portando arma de fogo, enquanto o outro a rendeu e ordenou que ela fosse até o cofre, de onde subtraiu todo o valor em espécie que lá havia. Não se recorda do valor subtraído. Afirmou que foram subtraídas também cinco pilhas. Nenhum bem foi recuperado. Após a subtração, os roubadores deixaram o local. Confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia dos dois assaltantes e depois o pessoal de um deles. Disse que, com relação a um dos roubadores, ela o reconhece perfeitamente e

tinha certeza do reconhecimento, sendo aquele assaltante que a levou até o cofre. Afirmou que o nome dele é Sávio. Disse que teve dúvidas quanto ao reconhecimento do outro roubador. Afirmou que o roubador que a levou até o cofre, estava de óculos escuros e boné. Disse que posteriormente, cerca de quinze ou vinte dias depois, foi assaltada novamente pelos mesmos roubadores. Por fim, não reconheceu Sávio como um dos autores do roubo. Reconheceu Jonathan como o roubador que a conduziu ao cofre e que não lhe exibiu arma de fogo (fls. 317).

A testemunha João Paulo Fernandes Vasques Senhoraes, policial civil, narrou que tinham o conhecimento de alguns roubos praticados com o mesmo modus operandi, sendo que por ocasião de um desses crimes foi encontrado documento pertencente ao corréu Jonathan. Afirmou que, paralelamente, investigavam Savio por envolvimento em um crime de tentativa de latrocínio e receberam informação de que ele poderia estar envolvido também nos roubos às farmácias. No caso do crime narrado na denúncia, entraram em contato com uma pessoa que estava presente no local no dia dos fatos e esta compareceu na delegacia de polícia e reconheceu fotograficamente Sávio e Jonathan como os autores do roubo (fls. 318).

A testemunha policial civil Diego da Silva disse que durante um roubo tendo como vítima um policial militar, um dos roubadores, ao fugir, deixou cair a carteira contendo um documento de identidade de Jonathan, mas não sabiam onde ele poderia ser localizado. Já Sávio estava sendo investigado por uma tentativa de latrocínio e acabou sendo reconhecido por alguns funcionários da farmácia Droga Raia como um dos autores dos roubos às farmácias em companhia de Jhonatan. Disse que não conversou com Jonathan, apenas com Sávio, que negou a prática dos fatos (fls. 319).

Interrogado em juízo, o réu Sávio negou a prática do roubo e disse nada saber sobre o crime. Alegou desconhecer o corréu Jonathan (fls. 320).

Já o réu Jonathan confessou a prática delitiva. Contou ter ingressado no estabelecimento comercial juntamente com um comparsa, de vulgo Alemão, que portava um simulacro de arma de fogo. Disse que rendeu a funcionária e subtraiu o dinheiro que estava no cofre. Após, deixou o local. Disse que Sávio não participou do crime. Não se recorda a quantia subtraída. Não conhecia a vítima ou os policiais ouvidos em juízo como testemunhas. Cumpre pena pela prática de roubo (fls. 321).

A negativa sustentada pelo corréu Jonathan quanto ao emprego de arma de fogo, porém, se mostra inaceitável.

A vítima relatou com detalhes a prática do roubo e foi enfática ao narrar que um dos roubadores ingressou no estabelecimento comercial portando uma arma de fogo. Reconheceu, ainda, o corréu Jonathan como o roubador que não lhe exibiu a arma de fogo, mas que lhe rendeu e a levou até o cofre, de onde foi subtraída toda a quantia em dinheiro que havia.

E a apreensão da arma não é imprescindível para o reconhecimento de seu emprego pelos agentes do roubo, se sua utilização no crime está relatada nas declarações do ofendido, firmes e consentâneas com as demais provas colhidas, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminar falsamente inocentes seus desconhecidos.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

“ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,

coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]” (TJSP, Apelação Criminal n.º 0145056-89.2008.8.26.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26/07/2011.v.u).

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

Nessas condições, inviável a absolvição do corréu JONATHAN GIMENEZ.

Por outro lado, as provas produzidas se mostraram insuficientes para a condenação do corréu SÁVIO CONCEIÇÃO DA COSTA pela prática do crime narrado na denúncia.

Em juízo, a vítima não reconheceu o corréu Sávio como um dos roubadores e afirmou que só teve certeza do reconhecimento extrajudicial do roubador que a levou até o cofre. Embora tenha afirmado que o nome dele seria Sávio, o que se justifica pelo tempo decorrido desde a data dos fatos, apontou Jonathan, tanto em juízo, como perante a autoridade policial (fls. 5), como o agente que a conduziu até o cofre e que subtraiu de lá o dinheiro do estabelecimento,

Nessas circunstâncias, a dúvida quanto à sua efetiva contribuição na execução do crime lhe favorece.

Como é sabido, “Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade” (Heleno Cláudio Fragoso, Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p.506).

Resta a fixação das penas em relação ao réu JONATHAN GIMENEZ.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como os maus antecedentes do acusado, conforme fls. 339/340 (Processo nº 1502791-16.2017.8.26.0536), fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias multa.

A condenação anterior supra mencionada, embora não caracterize a circunstância agravante da reincidência, integra o conceito de "maus antecedentes".

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação

deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem, o que ocorreu na espécie. 2. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena inferior a quatro anos, mesmo diante da primariedade do réu. 4. Ordem não conhecida" (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal em destaque, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. Habeas corpus não conhecido" (HC 319.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 19/06/2015).

Reconheço a atenuante relativa à confissão espontânea e reduzo a pena retro fixada para o mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento a pena retro fixada pela prática do crime de roubo de dois terços (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), observando que no concurso de causas de aumento prevalece a causa que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Tal resulta em seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, porquanto a ousadia e periculosidade do réu, portador de maus antecedentes, está demonstrada pelo modo de intimidação da vítima, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. O roubo em tais circunstâncias consiste em crime gravíssimo, a demonstrar ousadia e periculosidade do agente, incompatível com cumprimento da reprimenda em regime penal mais brando.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o faço para: a) com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolver o réu SÁVIO CONCEIÇÃO DA COSTA da acusação de cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e b) por incursão nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, CONDENAR JONATHAN GIMENEZ, qualificado nos autos, às penas de seis anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de dezesseis dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu solto ao processo. Aparentemente ausente periculum libertatis nesta fase, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Defiro aos réus, assistidos pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 283). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA